

1521853-88.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/10/2022

... fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1521853-88.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1521853-88.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO AQUINO CORREIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

SÉRGIO AQUINO CORREIA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 16 de outubro de 2020, por volta das 21h20min, em ocasião de calamidade pública, na Rua do Pacificador, altura do nº 41, Sacomã, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 203 porções contendo a substância Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida, inicialmente o réu não foi encontrado para ser citado pessoalmente, mas constituiu advogado particular (fls.80) e apresentou sua resposta a acusação a fls.107/112.

Mantido o recebimento da denúncia e designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidos dois policiais, duas testemunhas de defesa e réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa pugnou pela absolvição do réu pela improcedência da ação penal por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). Em caso de eventual condenação, requereu a fixação da pena em seu piso mínimo, a aplicação da benesse prevista no §4º, do art.33 da referida lei, com fixação de regime aberto para início de

cumprimento de pena e ainda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial com resultado POSITIVO para maconha. (fls.85/87)

A autoria também é inconteste.

Com efeito, os dois policiais ouvidos em juízo confirmaram que estava em patrulhamento pelo local dos fatos e se depararam com o réu na condução de uma motocicleta, sem a utilização de capacete e em razão dessa infração resolveram aborda-lo. Durante a revista, no guidão da motocicleta havia uma sacola, dentro da qual foram encontradas aproximadamente 200 porções de maconha e uma certa quantia em dinheiro e ao ser indagado sobre as drogas, o réu disse que estava transportando o entorpecente para abastecer uma biqueira e diante disso foi preso em flagrante. As duas testemunhas de defesa, ouvidas em juízo, disse que estavam bebendo na companhia do réu e que como a bebida acabou pegou a moto e foi ao bar comprar mais bebidas, mas não voltou, sendo que posteriormente disseram que tomaram conhecimento de que ele havia sido preso.

Não presenciaram a prisão do réu, mas viram que um outro motoqueiro passou pelo local e jogou uma sacola ao chão e que dentro dessa sacola havia entorpecentes que foram apreendidos pela polícia.

O réu ao ser interrogado em sede policial preferiu permanecer em silêncio, em juízo, confirmou que estava bebendo com seus amigos e como a bebida acabou foi ao bar comprar outras garrafas de moto, e não usava capacete e na volta foi detido pelos policiais que encontraram uma sacola em um entulho.

Disse que não era verdade que trazia a sacola no guidão de sua motocicleta, mas não soube informar o motivo pelo qual os policiais lhe atribuíram a propriedade da sacola.

Ora, a versão do réu é incrível e não veio corroborada nos autos, com efeito sequer suas testemunhas apresentaram a mesma versão sobre os fatos, alegando que um outro motoqueiro desconhecido jogou a sacola no chão e não em um entulho como narrado pelo réu.

Por outro lado, dos dois policiais foram uníssonos nas versões apresentadas e nas duas oportunidades em que foram ouvidos em juízo, afirmaram que a apreensão da droga com o réu ocorreu por acaso já que ele fora a princípio abordado apenas porque estava conduzindo sua moto sem capacete.

Há que se asseverar, ainda, que o simples fato de a testemunha ouvida ser policial nada significa para que seja desconsiderado seu depoimento ou que este seja recebido com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas. Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos. Não é suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de agentes policiais.

Ressalte-se que a diligência policial promovida neste processo decorreu, em tese por uma infração administrativa no trânsito, sem que haja qualquer indício que qualquer perseguição pelos policiais houvesse em relação ao acusado, e, para espantar qualquer dúvida em relação à eventual suspeição por parte dos policiais, o

réu, em nenhum momento alegou haver qualquer tipo de perseguição contra o acusado por parte da polícia.

Confira-se: "Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

Dessa forma, considerando-se que o réu não produziu prova alguma capaz de infirmar os fatos que lhe são atribuídos na denúncia merece total acolhimento a pretensão punitiva e uma vez que as condutas dos réus subsumem-se ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é de rigor a condenação do réu.

Passo a individualizar a pena a ser aplicação ao acusado:

Em atenção aos ditames do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário e não possui antecedentes criminais atestados. (fls. 26/27).

Assim, é o caso de se aplicar a pena base fixada em seu mínimo legal, consistente em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a se considerar.

Presente contudo a agravante prevista no art. 61, II, alínea "j", do CP, já que o crime foi cometido em junho de 2020, durante situação de calamidade pública, que assola o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020 em que estávamos todos presos em nossas casas, sem saber quando poderíamos sair e se iríamos ou não ter algum remédio ou vacina eficaz para conter o vírus.

Neste ponto, respeitadas posicionamentos em contrário, para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal.

Desse modo, a pena deve ser agravada em 1/6, chegando ao patamar de 5 anos, 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais:

"Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos" (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: "(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

"Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua

configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias." (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo Autos nº 1509419-67.2020- "O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença", escreveu o magistrado em seu voto. "De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência."

"O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), "a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda" (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

"Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC

nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

STJ - "(...) impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61, II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda população do Município, colocando em risco a saúde pública" (HC nº 584.871, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2020, DJe 08.06.2020).

TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL (...) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP -Descabimento Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 -Inexigência legal de outros requisitos para caracterização da agravante (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1510315-13.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, J. 16.10.2020).

Com idêntico raciocínio: Apelação nº 1507788-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 21.09.2020; Apelação nº 1513982-07.2020.8.26.0228, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Freitas Filho, j. 19.01.2021.

9ª Câmara Criminal- Des. Fátima Gomes: "Com efeito, na alínea "j" do inciso II do art. 61 do Código Penal, encontra-se previsão para a agravação da pena diante de circunstâncias que representem o aproveitamento por quem realiza o crime da existência de uma situação de perigo comum. Cabe notar não ser necessário que o sujeito crie a situação de perigo, mas que apenas a aproveite. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias.

Na situação especial, o apelante aproveitou-se de acontecimentos de especial relevo para a vida da população. O acontecimento e seus efeitos maléficos devem, obrigatoriamente, ser conhecidos por quem deles conscientemente aproveita-se.

Nesse sentido: "Essa circunstância implica maior gravidade do injusto, de modo a agravar o desvalor da ação, dado que a produção do resultado delituoso se revela mais provável. É necessário que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, da ocasião ou do momento particularmente difícil em que se encontra a vítima, com o fim de dificultar sua defesa. Tal agravante também se fundamenta em razões político-criminais, pois o agente pode prevalecer-se das circunstâncias não apenas para debilitar a defesa da vítima, mas também para facilitar sua impunidade." (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: Jurisprudência, Conexões Lógicas com os Vários Ramos do Direito. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 335).

Assim, referida agravante tem natureza objetiva, estampada no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e, diante da notória calamidade pública gerada pela pandemia do vírus covid-19, mostra-se absolutamente desarrazoada a pretensão defensiva de afastá-la.

Veja-se que na data em que os fatos ocorreram estávamos diante de uma pandemia que vinha causando a morte de inúmeras pessoas e somente o isolamento social era possível.

Na terceira fase da dosimetria da pena, considerando a primariedade do acusado e o fato que não há provas de que ele se dedique a atividades criminais, a pena deve ser diminuída nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Portanto, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzo a pena em 1/3, resultando 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 388 dias-multa, que fixo em seu valor unitário mínimo a mingua de provas a respeito da condição econômica do réu.

Veja-se que a lei determina que a redução deve ser de 1/6 a 2/3 e diante disso

considerando a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas com o réu, ou seja, mais de 200 porções de drogas, pena não deve ser diminuída no máximo legal, como pretendido pela Defesa.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu -lo como incurso nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, aplicando-se ao réu a pena de 03 ano, 10 meses e 20 de reclusão, e 388 dias-multa, no mínimo legal, já que não há nos autos provas de sua condição econômica.

Em face das decisões reiteradas das cortes superiores, e, sobretudo, pelo fato de que o acusado é primário, de bons antecedentes e crime este que não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, e ainda considerando o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto.

Nos termos do disposto no art. 44 do Código penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, que ficam ora estabelecidas por uma pena de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena substituída e por outra pena de prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social, nos exatos moldes determinados pelo Juízo da Execução Criminal.

Nos termos do disposto no art. 77, inciso III, do Código Penal, deixo de aplicar o réu o "sursis".

Tendo em vista que o réu foi solto durante o tramite do processo e que não estão presentes os requisitos autorizadores de sua prisão cautelar, poderá apelar desta em liberdade.

Determino ainda a destruição de todos os entorpecentes apreendidos nestes autos, inclusive eventual contraprova. Oficie-se a autoridade policial para providenciar a devida destruição nos termos da lei.

Declaro ainda, a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos exatos termos do que dispõe o art. 63 da Lei 11.343/06

Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso, oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Com a juntada dos cálculos aos autos abra-se vistas às partes para ciência e eventual manifestação.

Condeno ainda o acusado ao pagamento da taxa judiciária, nos exatos termos legais, já que não há nos autos provas de que não pode arcar com essa despesa, sem prejudicar o seu sustento.

Ressalte-se que a condenação ao pagamento das taxas judiciárias decorre de expressa previsão legal. O Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Poderá, o réu, porém, caso demonstre preencher a hipótese legal, valerem-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, Dje 14/06/2011). P.R.I.C.

São Paulo, 16 de outubro de 2022.

Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA